

1513553-06.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513553-06.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513553-06.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150115/2021 - 73º D.P. JACANA, 18286958 - 73º D.P. JACANA, 2852/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2150115 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), na data de 02 de junho de 2021, por volta das 14h00, na Rua Luis Martins, nº 100, Tremembé, nesta comarca e capital de São Paulo, menor de 21 anos, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus (COVID-19), trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiros, 21 porções de maconha, num total de 65,9g; 18

porções de maconha sob a forma de haxixe, num total de 15,4g; e 14 porções de cocaína, num total de 9,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado trazia consigo, no interior de uma pochete, os entorpecentes mencionados, com o propósito de entregá-los a terceiro para fins de tráfico.

Relata a inicial que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o denunciado na via pública, acompanhado de outro indivíduo, os quais empreenderam fuga ao avistarem os milicianos, todavia MAYCON foi alcançado e com ele foi encontrada uma pochete, dentro da qual estavam as drogas.

Narra a exordial que a variedade de substâncias, individualmente embaladas, bem como a quantidade, indicam de que se destinavam ao comércio espúrio.

Por decisão exarada em 03 de junho de 2021, a prisão preventiva foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 50/53).

Foi impetrado Habeas Corpus com pedido liminar, pela Defensoria Pública, em favor do acusado, requerendo, em síntese, o direito à liberdade do acusado (fls. 67/75).

A medida liminar pretendida foi deferida em parte, determinando a expedição de alvará de soltura clausulado e fixando a medida cautelar alternativa consistente na proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (fls. 76/78).

Foi expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 79/80). O acusado foi posto em liberdade (fls. 86/88).

Sobreveio aos autos notícia de que o réu foi preso por outros autos, no CDP Belém I (fls. 106/107).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 16 de novembro de 2021 (fls. 119/120).

A audiência designada para o dia 16 de novembro de 2021 deixou de ser realizada em virtude da ausência do réu. A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado.

Na sequência, foi recebida a denúncia e, ao fim, foi redesignada audiência virtual para o dia 14 de junho de 2022 (fls. 140/141).

O acusado foi intimado pessoalmente a comparecer à audiência supra redesignada (fl. 154).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, menor de 21 anos de idade, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Constatação (fls. 29/31), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 109/111, 132/134), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, depreende-se do Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 203352/2021, de fls. 109/111 e 132/134, resultado positivo para as substâncias tetrahydrocannabinol (Itens 1 e 2) e cocaína (Item 3).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Rafael de Oliveira Costa, policial militar, relatou, em suma, que estavam em patrulhamento pelo local e ao fazer uma incursão a pé visualizou ele com posse da pochete e quando ele viu a presença sua correndo e tentou se esconder em uma borracharia. O réu estava sem camisa e trazia uma pochete, na mão. Enquanto visualizou ele segurava a pochete na mão. Não perdeu de vista enquanto o réu corria. Dentro da pochete tinha outra pochete menor contendo os entorpecentes. A quantidade exata não lembra. O réu não falou nada. Tinha mais pessoas que correram juntas. Desde o princípio viu o réu com a pochete.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Matheus Gonçalves Barboza, policial militar, que narrou, em síntese, que chegou a ler o B0 e se recordou dos fatos. A equipe estava em patrulhamento quando visualizaram um indivíduo sem camisa, de bermuda, com uma mochila e ao visualizar a equipe começou a correr pelas escadarias da comunidade. O motorista da equipe começou a correr e o depoente ficou na viatura. O motorista da equipe conseguiu capturar o indivíduo na posse de uma mochila contendo entorpecentes. Acha que tinha maconha, haxixe, Era uma pochete que pendura no corpo. Não viu o momento em que o indivíduo foi preso. Reconhece o réu presente em audiência. Quando visualizou só conseguiu ver o réu.

Em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, o réu aduziu que está com 21 anos de idade. Mora com a prima e três primos. Estudou até a sétima série, oitava. Parou de estudar porque trabalha, é pedreiro. Sempre trabalhou com o pai em obras. Estava no lugar sim. Tem um salão de cabeleireiro. Foi abordado. Os mesmos policiais abordavam o interrogando sempre, já havia sido abordado pelos mesmos policiais que hoje foram ouvidos umas cinco vezes. Das outras vezes pedem documento, olham que não tem nada e liberam. Na data desse fato estava sem camisa. Não deu a versão que está no termo de interrogatório a fl. 7. Não conhecia o delegado.

Ocorre que, diante dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (maconha, haxixe e cocaína); b) pela considerável quantidade de drogas (91,1g no total),

incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em porções), de modo a atingir diversos consumidores; d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Da circunstância agravante de pena prevista na alínea “j”, do inciso II, do artigo 61, do Código Penal (ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública).

Com efeito, em que pese o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia em razão do coronavírus (COVI-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos.” (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021). (grifos nossos)

No mesmo sentido: Apelação Criminal nº 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021; Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021 e Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme se infere da Certidão as fls. 130/131 e em observância ao disposto na Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 anos na data do fato, tendo à época, 20 anos (fl. 14). Deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses

termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, contava com 20 anos à época dos fatos, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade.

Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-

se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA